

1501142-13.2021.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: KATIA MARGARIDO BARROSO

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... de agentes para a prática de crime de tráfico. (in, Leis penais e processuais penais comentadas. 2ª ed., RT. p.334).

E também alguns Tribunais. Sob essa última, ótica, veja-se:

EMENTA: TÓXICOS - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PROVAS - DEPOIMENTOS

PRESTADOS POR POLICIAIS - VALOR PROBANTE - CONDENAÇÃO - DELITO DE ASSOCIAÇÃO -

INSUFICIÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá

Foro de Guaratinguetá

1ª Vara

Av. Dr. Ariberto Pereira da Cunha, 280, Guaratinguetá-SP - cep 12516-410

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501142-13.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO

Aos 12 de setembro de 2022 faço conclusão dos autos a Dra. Katia Margarido Barroso, Juíza Direito Auxiliar. Eu, Digitei.

Processo Digital nº:

1501142-13.2021.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2347542/2021 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 22080119 -

DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 1002/21/514 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 2347542

- DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 2347542 - DISE- DEL.SEC.GUARATINGUETA, 1002/21/514

- DISE- DEL.SEC.GUARATINGUETA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO EDUARDO SANTOS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). KATIA MARGARIDO BARROSO

Vistos.

CAIO EDUARDO SANTOS DA SILVA está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, por incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e artigo 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque, nos

termos do relato trazido na denúncia: "Em data pretérita indeterminada até o dia 21 de dezembro de 2021, por volta de 17 horas, Rua Antenor de Vasconcelos Cardoso, nº 670 lado esquerdo, bairro Vila Comendador, nesta cidade e comarca de Guaratinguetá-SP, CAIO EDUARDO SANTOS DA SILVA, qualificado às fl. 10, associou-se ao adolescente Douglas Willian Ferreira Dias Nogueira, para o fim de praticar, reiteradamente, crime de tráfico de drogas. Outrossim, consta que, no dia 21 de dezembro de 2021, por volta de 17 horas, Rua Antenor de Vasconcelos Cardoso, ao lado do nº 670, bairro Vila Comendador, nesta cidade e comarca de Guaratinguetá-SP, CAIO EDUARDO SANTOS DA SILVA, agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, com o adolescente Douglas Willian Ferreira Dias Nogueira, guardava e mantinha em depósito, para fins de consumo de terceiros, 86 g (oitenta e seis gramas) de cocaína, 74 g (setenta e quatro gramas) de Cannabis sativa L e 352 g (trezentos e cinquenta e dois gramas) de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão inserido às fls. 21/24 e laudo de constatação provisória encartado aos autos às fls. 40/44. Por fim, consta que, nas mesmas condições de tempo e local supra, CAIO EDUARDO SANTOS DA SILVA corrompeu o adolescente Douglas Willian Ferreira Dias Nogueira, com ele praticando infração penal. Segundo apurado, em data indeterminada, o denunciado cooptou o adolescente em questão, com ele estabelecendo associação, para, mediante reunião de esforços, de maneira estável, adquirem drogas para fins de venda a usuários. Para tanto, CAIO e o menor passaram a utilizar uma casa abandonada, onde guardavam o entorpecente, embalavam e distribuíam a terceiros. A atividade de traficância somente foi interrompida com a chegada dos policiais militares ao local, os quais, suspeitando da intensa movimentação no imóvel, adentraram o mesmo, logrando surpreender CAIO na posse de uma pochete, na qual havia 30 (trinta) tubos eppendorf, contendo de cocaína, 15 (quinze) pedras de crack, 05 (cinco) porções de maconha, além de um celular Samsung, utilizado para contatar usuários e fornecedores. Já em poder do menor, foram apreendidos 34 (trinta e quatro) pinos de cocaína, 20 (vinte) pedras de crack, 01 (uma) porção de maconha e R\$32,00 (trinta e dois reais) em dinheiro, proveniente do lucro do comércio espúrio. Ato contínuo, os milicianos efetuaram buscas pelo imóvel, onde apreenderam um rolo de papel alumínio, uma balança digital e uma pedra grande de crack. Ante tais evidências, CAIO foi preso em flagrante. Saliente-se que o investigado, ao tornar possível o ingresso do adolescente na atividade ilícita de tráfico de entorpecentes, o introduziu na senda do crime" (fls. 133/135).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 62/66 e 91).

Depois da respectiva notificação, a defesa preliminar foi apresentada (fls. 165/167).

A denúncia foi recebida em 11 de maio de 2022 (fls. 168/169).

Durante a instrução foram juntados documentos e colhidos os depoimentos de três testemunhas. Logo após, o réu foi interrogado (fls. 197/201).

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça, depois de analisar as provas, pediu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. Diante da quantidade, variedade e nocividade das substâncias apreendidas, pediu que a pena base fosse fixada acima do mínimo legal, com o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos. Igualmente pediu que fosse declarada a perda da quantia apreendida. A Defesa, por sua vez, pugnou por solução favorável ao réu. Na oportunidade, disse que as teses acusatórias não restaram confirmadas em juízo. Argumentou que inexistente no processo prova da associação e de que ela fora constituída de maneira estável e permanente. Pontuou que, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, a associação eventual não basta para permitir o reconhecimento do tipo penal. Lado outro, sustentou que o testemunho dos policiais não é capaz de indicar qual era a conduta descrita no art. 33 da Lei de Tóxicos que estaria sendo praticada pelo réu. Desse modo, criticando a prova produzida, pugnou pela

absolvição do acusado. Alternativamente, para o caso de condenação, referiu que a confissão do réu quanto ao tráfico não pode deixar de ser considerada na dosimetria da pena. A par disso, invocando o princípio da especialidade, aduziu que a conduta quando muito atrairia a figura do art. 40, inciso VI, da Lei de Tóxicos e não a figura penal prevista no ECA. Pediu na hipótese de condenação, o reconhecimento da figura privilegiada do tráfico. Ao final, invocou os incisos IV e VII do art. 386 do CPP (fls. 209/214 e 219/227).

Relatei.
DECIDO.

A materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei de Tóxicos está comprovada.

Nesse particular, têm-se documentos diversos: a. auto de exibição e apreensão de fls. 21/24, b. Fotografias de fls. 25/28, laudo de constatação provisória da droga de fls. 40/44 e c. laudo de exame químico toxicológico de fls. 148/151, estes com a conclusão de que as análises no material apreendido revelaram resultado positivo para cocaína e maconha.

Por outro lado, a autoria do apontado delito igualmente é certa.

Com efeito, a vinculação do réu o delito vem confirmada por toda a prova oral, inclusive confissão judicial.

Na hipótese, o relato dos policiais é detalhado, isto é, sob o crivo do contraditório não só fizeram menção a apreensão da droga, como igualmente disseram que no momento da abordagem tanto o réu, quanto o adolescente admitiram a traficância. De mais a mais, contaram que os dois foram vistos comercializando o entorpecente e, ainda, que cada um deles tinha atrelada ao corpo uma pochete com drogas.

Desse modo, bem caracterizado o tráfico.

Quanto à validade do depoimento de policiais, convém a transcrição dos seguintes julgados:

A prova, em que pese a alegação dos réus, embora emanada de policiais, é válida, já que o fato de serem policiais não a invalida, no conceito mais alto do Supremo Tribunal Federal, que assim doutrinou e assentou [...] 'Os agentes policiais podem ser testemunhas e são presumidamente idôneos por exercerem função pública de relevante interesse social. R. Criminal de que não se conhece - RCr. n. 86.926-PR, Rel. Sr. Ministro CORDEIRO GUERRA, STF.

Não se pode presumir, em policiais ouvidos como testemunhas, a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente [...]. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes [...]. - RT 614/275.

Pelas razões antes explicitadas, não é caso de absolvição e nem de desclassificação da conduta.

De outro lado, como se sabe, não são poucos os usuários que também comercializam drogas.

Sob essa ótica, veja-se:

A condição de usuário não exclui o crime de tráfico de entorpecente - Ap. Criminal n. 1021/84 - Rev. dos Tribunais, vol. 995, págs. 408/410.

Por fim, quanto ao dinheiro apreendido, vez que as circunstâncias indicam que ele é proveniente da infração apurada, fato que foi informado pelo réu e pelo adolescente aos policiais, também o pedido que visa seja decretado o respectivo perdimento deve ser acolhido.

Nestes termos, para o tráfico, a condenação se impõe.

De outro lado, quanto ao delito tipificado no art. 35 da Lei de Tóxicos, conquanto respeitáveis as ponderações da acusação, consigno que a prova não foi capaz de determinar o seu reconhecimento.

Com efeito, os informes colhidos não permitiram a caracterização das exigidas estabilidade e permanência.

Ressaltando-se, como é sabido, que para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei de Tóxicos não é suficiente a existência do simples dolo de agir conjuntamente, em concurso. É imprescindível a verificação do dolo específico, isto é, o dolo de associar-se de forma estável.

Roborando as colocações acima, assim já se posicionou Guilherme Nucci:

Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa (...). vExige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática de crime de tráfico. (in, Leis penais e processuais penais comentadas. 2ª ed., RT. p.334).

E também alguns Tribunais. Sob essa última, ótica, veja-se:

EMENTA: TÓXICOS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PROVAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO – DELITO DE ASSOCIAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/06 – POSSIBILIDADE - ... RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS - (...) Inexistindo a prova da habitualidade, permanência ou estabilidade, impõe-se a absolvição pelo art. 35 da Lei n. 11.343/06 (...) APELAÇÃO CRIMINAL N. 1.024.07.482375/001 – COMARCA DE BELO HORIZONTE – RELATOR DES. JOSÉ ANTONIO BAÍAS BORGES; 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS; data do julgamento 10/09/2008. No caso, diga-se: muito embora os policiais tenham flagrado o réu e o adolescente em um contexto que evidencia a participação de ambos no comércio ilícito, não existem nos autos outros elementos a indicar que a associação tivesse sido estabelecida de forma estável.

Destacando-se nesse ponto que os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando fizeram a incursão por saberem que o local é conhecido como um ponto de venda de entorpecentes (para a data referenciada na denúncia, não há registro de prévia denúncia envolvendo o nome do acusado ao adolescente). Além disso, de acordo com a prova oral, há na Vila umas quatro casas abandonadas, todas usadas para a venda de entorpecente.

Lado outro, na confissão judicial Caio disse que havia entrado para 'o corre' há apenas quatro dias porque pretendia angariar dinheiro para uma cirurgia. Referiu que não sabia que Douglas era menor de idade, tendo esclarecido que estava perto dele apenas porque varios traficantes vendem entorpecente no local.

Assim, quanto ao crime tipificado no art. 35 da já referida Lei n. 11.343/06, por debilidade do conjunto probatório, o acusado será absolvido.

Demais disso, no pertinente a outra imputação (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente) conquanto respeitáveis as ponderações da Acusação, também por debilidade do conjunto probatório, impõe-se a absolvição.

De fato, não é de hoje que parte da doutrina e da jurisprudência sustentam que tal crime só se aperfeiçoa com a efetiva comprovação de que o menor tenha se corrompido, não bastando para tal caracterização a prática de um único ato criminoso em concurso com o maior de idade.

Nesse sentido, para a conduta que vinha tipificada no art. 1º da Lei n. 2.252/54, veja-se:

CORRUPÇÃO DE MENORES - Caracterização. Para a configuração do crime previsto no artigo 1º da Lei nº 2.252/54 é necessário que o agente tenha, de qualquer forma, contribuído para a participação do menor no crime. O mero fato de ter praticado o ato criminoso em companhia do menor não tipifica esse delito. Para que haja o delito de corrupção de menores é necessário que o agente pratique uma das condutas descritas no tipo legal: facilitar ou corromper, não sendo suficiente para caracterizá-lo o fato de haver participado do crime criminoso em companhia de menores.

(STJ - REsp. nº 127.692 - DF - Rel. Min. Edson Vidigal - J. 16.12.97 - DJU 19.05.98).

E, no caso, conforme antes referido, sequer há prova capaz de demonstrar que réu e adolescente eram amigos.

Nestes termos, a ação é parcialmente procedente.

Na aplicação da pena tenho em conta os critérios dos arts. 59 e 60 do Código Penal. O réu é primário (fls. 47/48) e na audiência de instrução confessou a prática do tráfico. De outro giro, ainda não havia completado 21 anos de idade na data dos fatos. Assim, sua pena base pode ser fixada no piso mínimo, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A par disso, por força do estabelecido no art. 33, § 4º, da lei já referida, tal pena deve ser diminuída de 2/3 (dois terços); de modo a ficar fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada dia-multa estabelecido no menor patamar.

No mais, muito embora este Juízo não comungue da tese, é certo que o E. Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a possibilidade de concessão de regime aberto e eventual aplicação de penas alternativas nos crimes de tráfico.

Nesse sentido:

Habeas Corpus. Constitucional e penal. Tráfico de entorpecentes. Substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos. Possibilidade. A jurisprudência desta Corte está alinhada no sentido do cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por outra, restritiva de direitos, nos crimes de tráfico de entorpecentes. Nesse sentido, o HC n. 93.857, Cezar Peluso, DJ de 16.10.09 e o HC n. 99.888, DJ de 12.12.10. Ordem concedida" (HC 102678, Relator Ministro Eros Grau).

Confira-se ainda: Habeas Corpus nºs 97.256/RSSTF e 177.946/MG-STJ.

Nestes termos, mostra-se viável a conversão da pena privativa de liberdade em (I) uma restritiva de direitos e (II) multa, consoante regra prevista no art. 44, § 2º, do Código Penal. Assim, a pena do réu fica estabelecida em - a. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (definição a ser feita pelo Juízo das Execuções), pelo prazo de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação e b. pagamento de multa, sendo 10 (dez) dias-multa em razão da substituição e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em razão da própria condenação. Todo dia-multa arbitrado no menor patamar.

No mais, vez que os informes colhidos indicam que o dinheiro apreendido era fruto da comercialização de drogas, de rigor o acolhimento do pedido que busca o seu perdimento.

Diante do exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para: (a) CONDENAR o réu CAIO EDUARDO SANTOS DA SILVA, qualificado a fl. 10, por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, a uma pena

restritiva de direitos: a. prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 01 (um) ano e 08 (oito) meses e b. 176 (cento e setenta e seis) dias-multa; estes correspondendo a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, devendo proceder-se ao respectivo reajuste de lei, na forma do art. 49, § 2º, do Código já indicado. Quanto à pena restritiva de direitos, conforme acima explicitado, o Juiz das Execuções determinará locais e condições para o cumprimento respectivo; devendo ela ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação e (b) ABSOLVE-LO das demais imputações, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Diante da pena fixada, o sentenciado poderá recorrer em liberdade e, se necessário, deverá iniciar o cumprimento de sua pena no REGIME ABERTO (art. 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal), mediante o atendimento das condições estabelecidas no art. 115 da Lei de Execuções Penais.

Além disso, como anteriormente deliberado, DECRETO o perdimento da quantia em dinheiro apreendida. Oportunamente, observando-se o artigo de lei invocado (art. 63 e § 1º, da Lei n. 11.343/06), expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

Com o trânsito em julgado, oficie-se a Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República.

De imediato, expeça-se alvará de soltura.

P.R.I.C.

Guaratinguetá, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA